

学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑩までの（ ）内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑩までの（ ）内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

居酒屋の店長甲は、客Xを殺害しようと考え、同店従業員Yに対し、ウイスキーを入れたグラスに致死量の毒薬を混入したことを秘して、同グラスをXの席に運ぶよう指示し、その指示に従ってYが同グラスを手にとろうとしたが、誤って同グラスを床に落としたため、Xを殺害するに至らなかった。

【会話】

学生A. 間接正犯の実行の着手時期について、私は、(①)と考えるので、(②)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪が成立します。

学生B. Aさんの見解に対しては、(④)という批判が可能ですね。私は、(⑤)と考えるので、(⑥)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪は成立せず、(⑦)罪が成立するにとどまります。私の考えは、離隔犯において、(⑧)時に実行の着手を認める考え方と親和的です。

学生A. Bさんの見解に対しては、(⑨)という批判が可能ですね。

学生C. 私は、(⑩)で実行の着手が認められると考えます。したがって、甲に(③)罪が成立するか否かは、結果発生の実質的危険性が発生したといえるかどうかの判断によることになります。

【語句群】

- a. 被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められる
- b. 実行行為者は利用者であり、被利用者の行為は因果経過にすぎない
- c. YがXの法益を侵害する行為を開始した時点
- d. 甲がYに働き掛けた時点
- e. 実質の見地から個別的にみて結果発生の実質的危険性が発生した時点
- f. 殺人予備 g. 殺人未遂 h. 発送 i. 到達
- j. 利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになる
- k. 結果発生の実質的危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになる

1. ①a ③f ⑥d ⑧h
2. ①b ④k ⑥c ⑨j
3. ②c ④j ⑦g ⑨k
4. ②d ⑤b ⑦f ⑩e
5. ③g ⑤a ⑧i ⑩c

No19	間接正犯の実行の着手時期	正答率
R7-12	正解 2	80%

() には順に、「① = b、② = d、③ = g、④ = k、⑤ = a、⑥ = c、⑦ = f、⑧ = i、⑨ = j、⑩ = e」と入り、したがって、正解は肢2となる。

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩について

間接正犯の実行の着手時期については、利用者標準説、被利用者標準説、個別化説という3つの見解がある。

このうち、学生Cは、その第一発言から間接正犯における実行の着手が認められるか否かは、結果発生の実質的危険性が発生したといえるかどうかを判断基準にしていることから、個別化説を採っているといえる。よって、⑩には「e. 実質的見地から個別的にみて結果発生の実質的危険性が発生した時点」が入る。

そして、学生Bの第一発言では、学生Bの見解からすると、「甲に(③)罪は成立せず、(⑦)が成立するにとどまります。」としていることから、罪刑の重い方が(③)、軽い方が(⑦)に入る。よって、③には「g. 殺人未遂」が入り、⑦には「f. 殺人予備」が入る。

そうすると、学生Aは、利用者甲が被利用者Yに対して毒入りグラスを運ぶように指示したものの運ぶ前に同グラスを割ってしまった設問の事例でもすでに殺人未遂罪が成立していると考えているので、利用者が実行行為者である以上、実行行為は利用行為であり、被利用者の行為は因果経過に過ぎず、利用行為の開始が実行行為の着手であるとする利用者標準説を採っているといえる。この説によると、設問の事例においては、甲がYに働き掛けた時点で実行の着手があるといえる。よって、①には「b. 実行行為者は利用者であり、被利用者の行為は因果経過にすぎない」が入り、②には「d. 甲がYに働き掛けた時点」が入る。

この利用者標準説には、被利用者の行為がなくても利用者が利用行為を開始した時点で実行行為の着手を認めてしまう点で、結果発生の実質的危険性が切迫していない状況でも実行の着手を認めることになってしまうという批判が可能である。よって、④には「k. 結果発生の実質的危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになる」が入る。

他方、学生Bは、設問の事例において、殺人未遂罪は成立せず、殺人予備罪が成立していると考えているので、結果発生の実質的危険性は被利用者の行為時に認められるとして、被利用者の行為の開始時を実行の着手とする被利用者標準説を採っているといえる。この説によると、設問の事例においては、YがXの法益を侵害する行為を開始した時点で実行の着手があるといえる。よって、⑤には「a. 被利用者の行為時に結果発生の実質的危険性が認められる」が入り、⑥には「c. YがXの法益を侵害する行為を開始した時点」が入る。

この被利用者標準説は、離隔犯において、結果発生の実質的危険性が認められるのは到達時であり、その時点で実行の着手が認められるという到達時説と親和的であるといえる。よって、⑧には「i. 到達」が入る。

そして、この被利用者標準説は被利用者の行為の開始時を基準とするので、利用者にとって偶然的な事情で実行の着手時期を決することになってしまうという批判が可能である。よって、⑨には「j. 利用者にとって偶然的な事情で実行の着手時期を決することになる」が入る。